

1500273-42.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... e não reconhecer a figura do tráfico privilegiado em virtude da ré responder a outra acusação de tráfico; deve ser fixado o regime inicial fechado. A douta defesa do réu Julio pleiteou a absolvição dele. Sustentou que: o réu atendeu à ordem de parada dada pelos policiais; ele havia recebido um pedido de carona feito pela corré e em nenhum momento percebeu que ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500273-42.2022.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171793/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 25755034 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2171793 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAROLINE SALES BENTO e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

08/08/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 08 de agosto de 2022, às 14h45, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Dr. Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Julio Henrique Venancio Batista, apresentado por teleconferência pela Penitenciária de Assis, a ré Caroline Sales Bento, o advogado Dr. José Roberto Magalhães OAB/SP 353.632 e Dr. Sérgio Afonso Mendes OAB/SP 137.370, as testemunhas Luciano da Rocha Maciel, Bruno Rafael Rocha dos Santos,

Maria José de Souza Amorim, Stefania de Oliveira Nascimento, Alessandro Venâncio de Almeida e Vânia Venâncio de Almeida. Ausente a testemunha Alice Rodrigues. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório dos acusados, a oitiva das testemunhas e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. O advogado do acusado desistiu da oitiva da(s) testemunha(s) Alice Rodrigues, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Julio Henrique Venâncio Batista e Caroline Sales Bento, qualificados nos autos, por terem, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. Narrou que no dia 24 de junho de 2022, por volta das 19h50min., na Av. David Passarinho, nº 1.460, Vila Souza, nesta cidade e Comarca, Julio Henrique e Caroline, em concurso e unidade de desígnios, traziam consigo, para entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 1.662,11g de maconha. Segundo apurado, Julio e Caroline traziam consigo 04 tabletes de maconha para a entrega a consumo de terceiros enquanto transitavam com o veículo VW/Saveiro, cor branca, placas DCY-9A04; o Pelotão de Força Tática recebeu a informação de que Caroline usaria uma Saveiro branca para buscar maconha para comercialização; avistaram os denunciados no veículo em movimento e abordaram; encontraram no assoalho do banco passageiro a vultosa quantia de maconha apreendida, dividida em tabletes envoltos em plástico amarelo e R\$ 394,00; a natureza e quantia das drogas, a forma de acondicionamento, o montante de dinheiro em espécie e as demais circunstâncias indicam que a droga se destinava à traficância. A denúncia foi recebida em 29/06/2022 (fls.101/103). Notificados, os réus apresentaram defesa (fls.131/133). Nesta data foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação apenas de Caroline. Sustentou que: os policiais disseram que a denúncia apontou apenas Caroline como traficante e que de imediato ela assumiu a propriedade da droga; a ré confessou em Juízo; há dúvida de que Julio soubesse da droga; os policiais não o conheciam do meio policial, falaram que numa simples observação não era possível ver que se tratava de entorpecente e que havia odor de maconha vindo do veículo; o relato desse odor não foi dito na fase inquisitória e não há como saber se o réu tinha como saber desse odor com o veículo em andamento; deve a pena ser exasperada rigorosamente pela quantia de droga traficada, ser aplicada a atenuante da confissão e não reconhecer a figura do tráfico privilegiado em virtude da ré responder a outra acusação de tráfico; deve ser fixado o regime inicial fechado. A douta defesa do réu Julio pleiteou a absolvição dele. Sustentou que: o réu atendeu à ordem de parada dada pelos policiais; ele havia recebido um pedido de carona feito pela corré e em nenhum momento percebeu que ela transportava drogas; o réu é primário, tem trabalho lícito e não tem envolvimento com crime organizado; não foi achado objeto característico de tráfico; o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho lícito; o réu não confessou; a ré falou que o Julio não sabia; o Ministério Público pediu a absolvição; não é possível afirmar que o réu tinha conhecimento do odor; no caso de condenação deve ser aplicado o redutor do art. 33, § 4º, ser feita a detração penal, ser fixado o regime inicial aberto e ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito; deve ser revogada a prisão preventiva do réu. A douta Defesa da ré Caroline requereu a consideração da confissão espontânea da ré; ela disse ter feito o crime por estar em dificuldades financeiras; a ré não agiu de forma dolosa; em caso de condenação deve ser aplicada a atenuante da confissão, ser afastado o aumento de pena do art. 61, II, do Código Penal, pelo período de pandemia ter cessado; deve ser fixado o redutor do tráfico privilegiado e pelo STJ a quantia de droga não é fator impeditivo do redutor; apesar dela ter sido condenada no outro processo deve incidir o princípio da presunção de

inocência; deve ser deferido o direito de apelar em liberdade. É o breve relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é parcialmente procedente. A materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da droga, auto de constatação provisória de droga e laudo de exame químico de entorpecente. Consta no laudo toxicológico que foram periciados fragmentos vegetais, cujo resultado foi positivo para Tetraidrocanabinol, substância indicada em lista proibitiva no Brasil. A autoria é certa e atribuída apenas à ré Caroline, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Julio negou o crime. Afirmou que nunca mexeu com estas coisas. Relatou que estava em sua adega, a ré lhe pediu uma carona e já deu caronas a ela para ir ao mercado, nunca imaginou que ela mexe com isso. Mencionou que é tatuador há oito anos, bem conhecido, não precisava disso. Declarou que é aposentado. Disse que a pegou na rua descendo a Davi Passarinho e foi abordado pela polícia, não ficou nervoso. Negou saber que ele transportava droga. Negou que a droga tivesse cheiro, se soubesse que tinha droga não andaria com o vidro aberto. Falou que já conhecia os policiais e eles já foram em seu estúdio na Otto Ribeiro. Frisou que quando a Carol entrou no carro a sacolinha ficou no colo e três ruas depois a polícia já abordou. Esclareceu que deu carona para a corré três vezes e não deu tempo de alguém ver. Negou ter ficado nervoso com a abordagem, é calmo e não devia nada à Justiça. Ressalto que se quisesse poderia correr e estava perto da pista. Comentou que o dinheiro é do auxílio e já pegou empréstimo de R\$ 17 mil. Narrou que tem três filhos e a guarda de um deles, ajuda os demais. Negou ter sido condenado, só quando de menor, com 12 anos, num roubo de bicicleta. Salientou que sua renda diária é de mil reais, cobra R\$ 250 por sessão e recebe benefício de R\$ 1200. A ré Caroline confessou o crime. Relatou que a droga apreendida era sua, comprou porque devia e precisava do dinheiro, iria revender. Mencionou que é amiga do Julio, ele já lhe ajudou e dividiram o aluguel, o réu abriu uma adeguinha em sua casa. Declarou que buscou esse negócio e subia a pé pelo Santa Clara, ficou nervosa e com medo de uma viatura. Salientou que pediu uma carona ao réu e ele nunca imaginou que carregava isso, ele faz na inocência. Contou que ele lhe pegou na rua principal do Santa Clara e estavam na Davi Passarinho, o policial pediu e ele parou. Negou ter cheiro de maconha no carro, se tivesse o menino sentiria. Informou que o credor lhe pressionou e fez essa loucura. Afirmou que tem dois filhos, o Pedrinho e o Davi. Negou que um leigo pudesse ver o que tinha dentro da sacolinha. Negou ter condenação, faz bicos como "diarista" e a renda varia. A testemunha Luciano afirmou que patrulhava pelo bairro Santa Clara e Santa Izabel e Prudenciana, obteve informações de que Carol buscava drogas no Santa Clara numa Saveiro de cor branca. Relatou que pela rua Santo Antônio viu a Saveiro, nele estavam Julio e Carol. Mencionou que abordaram na av. Davi Passarinho, dentro do carro havia sacola amarela com maconha e Carol assumiu a propriedade. Declarou que Julio lhe disse que Carol pediu para ele a levar no Santa Clara e depois foi abordado. Narrou que encontrou 300 e poucos reais na porta do motorista. Contou que Carol lhe disse ter pagado R\$ 800 pela droga e venderia por R\$ 1200, pois precisava para alimentação dos filhos. Esclareceu que a droga estava no assoalho do banco do passageiro, numa sacola de mercado amarela. Negou conhecer Julio como envolvido com crime. Frisou que é uma Saveiro rebaixada, para não colocar a abordagem em fuga pararam a viatura ao lado dele. Ressaltou que o réu Julio ficou nervoso com a abordagem policial e disse que a ré lhe chamou para uma corrida. Negou que na denúncia tenha dito de quem era a Saveiro branca. Negou que o réu tenha oferecido resistência. Disse conhecer Julio do bairro e nunca o viu em atitude suspeita. Negou que o réu tenha dito a origem do dinheiro, não perguntou a ele. Frisou que o odor de maconha de

dentro do veículo era muito forte. Tais informações foram confirmadas pela testemunha Bruno. Relatou que a droga estava no assoalho do passageiro, onde estava Carol, e que o odor de maconha no veículo era forte. Confirmou a apreensão de dinheiro na porta do motorista. Mencionou que Carol admitiu a propriedade da droga e Julio lhe disse que Carol falou para irem ao Santa Clara e tirar um objeto e que

não sabia o que se tratava. Declarou que Carol admitiu o tráfico e que comprou por R\$ 800 e que venderia por R\$ 1200. Negou conhecer Julio do meio policial. Esclareceu que no veículo já era forte o odor de maconha e acharam a sacola contendo o entorpecente. Frisou que Julio estava bem nervoso durante a abordagem e só declinou que a Carol lhe chamou para buscar algo no Santa Clara. Narrou que a droga estava em 3 pedaços, em plástico filme e plástico amarelo. Disse que salvo engano o veículo estava em nome de terceiro. A testemunha Maria José afirmou que conhece o Julio a quase dez anos e nunca viu a moça. Relatou que mora de frente ao estúdio dele e é amiga. Mencionou que o réu é excelente, respeitador e trabalhador, faz tatuagem. Negou saber de relação dele com drogas. Declarou que o réu é aposentado e tatuador. Negou ter ouvido falar que o réu comercializou drogas. A testemunha Steffânia afirmou que conhece o Julio há mais de dez anos. Relatou que ele faz tatuagem. Negou ter ficado sabendo que ele tem relação com drogas, é menino trabalhador, não tem nenhuma informação contrária a ele. Negou ter ouvido movimentação de pessoas atrás de drogas no local. O informante Alessandro afirmou que é tio do réu Julio. Relatou que ele nunca teve envolvimento com drogas, sempre trabalhou com tatuagem e nunca deu trabalho. Mencionou que o pai nunca foi presente e não teve envolvimento com nada disso. Narrou que o Julio tem uma filha. A informante Vânia afirmou que é mãe do réu. Relatou que seu filho nunca mexeu com isso e nunca lhe deu trabalho, ele sempre lhe ajuda em casa, a filha está sentindo muita falta. Negou conhecer a ré e nem saber o que ele foi fazer no dia da prisão. Disse que ele sofreu acidente, recebe benefício e trabalha como tatuador. Narrou que o réu cuida de três filhos. Negou ter ouvido falar de envolvimento dele com o tráfico. Informou que ele trabalha como tatuador faz anos. Pois bem. Ressalto que o tráfico de entorpecentes se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal. Segundo o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Os fatos foram comprovados pela prova oral. Os policiais militares narraram que receberam informação de que Caroline transportaria drogas numa Saveiro branca. Eles fizeram um patrulhamento e identificaram veículo com estas características, conduzido por Julio e que trazia Caroline como passageira. Fizeram a abordagem e constataram numa sacola, no assoalho da passageira, uma sacola plástica de cor amarela, na qual havia três tabletes de maconha. O auto de exibição e apreensão totalizou cerca de 1,6 kg de maconha. Os policiais falaram que Julio demonstrou nervosismo, falou que apenas dava uma carona à Caroline, enquanto esta assumiu a propriedade da droga e que era destinada ao tráfico de drogas. Por fim, falaram que havia forte odor de maconha no carro e que Julio não era conhecido nos meios policiais. As testemunhas de Defesa prestaram informações abonatórias sobre a conduta e vida pregressa do réu. É evidente que a destinação da maconha apreendida era o tráfico, notadamente em virtude da grande quantidade transportada, o que foi corroborado pela confissão de Caroline. Ela agiu com o dolo, consistente na vontade livre e consciente de transportar a droga com intuito de entregar ao consumo de terceiro. As dificuldades financeiras narradas pela requerida não justificam a conduta praticada e não acarretam a sua absolvição. É certo que deveria ter procurado obter recursos para pagar as duas dívidas com trabalho lícito, exatamente como fazem milhões de brasileiros diariamente. Por outro lado, como bem sustentado pelo douto Promotor de Justiça e douto Defensor, a prova é insuficiente com relação ao réu Julio. Embora tenha sido surpreendido dirigindo o carro onde estava a droga, há dúvidas acerca de que ele sabia que a corré estava com a maconha naquela sacola. Caroline sustentou que Júlio não sabia do entorpecente. Ainda que os policiais tenham dito que Julio demonstrou nervosismo, é

certo que ele parou o carro e não tentou fugir. Ainda que tenham comentado sobre o forte odor da droga, como bem notado pelo membro do Parquet não é possível ter certeza de que o réu sentiu esse odor com o carro em movimento e a janela aberta. Acrescente-se o fato que é pessoa primária e não era conhecida nos meios policiais. Dessa forma, concordo que há dúvida razoável acerca de sua participação, a qual lhe favorece. Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar apenas o decreto de condenação de Caroline pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito do art. 28 com relação a ela. Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor da ré qualquer dirimente: Consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena (STF, HC 127241/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado 04-08-2015, STF, RHC 117489/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 18-06-2013) e constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STF, RHC 122598, Rel. Min. Teori Zavaski, julgado em 14-10-14). A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevada intensidade pela espécie e pela grande quantidade de droga apreendida (mais de 1,6 kg de maconha). A vultosa quantidade revela o dolo exacerbado a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, possibilitando a circunstância ao agente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias. Ostenta outra condenação por tráfico de drogas, conforme certidão que será adiante juntada, a qual não interfere na pena base em atenção a entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça. Inexistem indicativos seguros quanto à personalidade. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase não é caso de aplicar a agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal. Isso porque o fato foi posterior ao dia 22/04/2022, em que o eminente Min. da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 (Ministério da Saúde declara fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Covid-19 - Português (Brasil) (www.gov.br)). Por outro lado, incide atenuante relativa à confissão espontânea perante Autoridade Judicial. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) e a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Não deve ser aplicada a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, levando-se em conta que Caroline já foi condenada por tráfico de drogas quando maior de idade pela 2ª Vara Criminal de Assis, conforme certidão de objeto e pé adiante juntada. É possível a utilização de processo em andamento para negar-se o privilégio, uma vez que, comprovadamente, a acusada se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido cito entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "...CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. (...) 5. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 6. Certo é que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possuem o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal. Essa, aliás, é a essência do princípio da presunção de não culpabilidade. Contudo, não há óbice a que processos em andamento ou mesmo condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possam, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerados elementos aptos a demonstrar, cautelarmente,

eventual receio concreto de reiteração delitativa (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas. 7. O registro de feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade podem afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador, quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, mas pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa. 8. É possível que o julgador que, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, possa livremente valorar as provas carreadas aos autos e os demais dados constantes do processo inclusive os depoimentos de testemunhas ou mesmo a confissão do acusado para, se for o caso, se convencer de que o agente não é merecedor do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se dedicar a atividades criminosas..." (STJ HC 338.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.12.2016, destaquei). Além disso, a expressiva quantia de entorpecente transportada (1,6 kg de maconha) torna inaplicável a referida causa especial de diminuição. Isso porque demonstrou que não era traficante ocasional. Ninguém começa traficando esta quantia de droga, inferindo-se destas circunstâncias que a ré já vinha se dedicando às atividades delituosas há muito tempo. Na esteira do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, "a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena" (REsp n.º 1.021.782, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22-3-2010). Nesse sentido é outro julgado do STJ: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELO EM LIBERDADE. ART. 44 DA LEI 11.343/07. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. [...] III. A redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 aplica-se aos delitos definidos no caput do referido dispositivo legal, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique ao crime ou integre organização criminosa. IV. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na hipótese dos autos, levando em consideração a quantidade de droga apreendida, bem como o indicativo de participação do paciente em organização criminosa. V. Ordem denegada. (HC n.º 194.483/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 28-4-2011 (destaquei). Aliás, importante frisar, como feito na fundamentação do aresto citado, que "a mens legis da causa de diminuição de pena é alcançar pequenos traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente com alto poder destrutivo" (HC 194.454, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 11/04/2011). Nesse sentido cito voto do Exmo. Desembargador Costabile e Solimene, no julgamento da Apelação nº 0000187-61.2017.8.26.0600, pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13/05/2019, que afastou a causa de diminuição de pena para pessoa que transportava 2 "tijolos" de cocaína, com peso de 1.985,77g. Confira-se: O redutor não é aplicável porque é evidente que pessoa que tem em sua posse esta expressiva quantidade de entorpecente está vinculada à organização criminosa. Nenhum traficante neófito poderia possuir aquele enorme volume. Pelos mesmos motivos, o regime é o fechado. Respeitosamente, quantidades elevadas são denotadoras de que o agente, para ter acesso a elas, incorporou-se à organização criminosa, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013). Acerca do transportador, o col. Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo aresto, deu paradigma para recusar o privilégio para o 'mula', confira-se: "(...) PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do réu a atividades criminosas, surge

inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006" (STF, HC 135.281, j. 18.12.2018). O rel., Min. MARCO AURÉLIO, de modo objetivo prelecionou, 'verbis': "(...) Observem a motivação lançada pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Considerou a dedicação a atividades delitivas, levando em conta o fato de o paciente exercer a função de transportador "mula". Atuou estritamente no campo técnico. O mula é o elo entre o fornecedor e o destinatário da droga, sendo pessoa de confiança do grupo criminoso. Configurado o envolvimento em organização criminosa, não cabe a redução da sanção". O e. STJ segue no mesmo sentido (AgRg no AREsp 962.949/SP, rel. o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29.8.16: "(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que o acusado, enquanto no exercício da função de transportador ("mula"), integra organização criminosa e, portanto, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06". Não se há confundir a teleologia do redutor, voltado para infratores de menor potencial, o que não é o caso. Oportuno remeter ao escólio do E. Des. GERALDO WOHLERS, da 3ª Câ. de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, Apel. n. 0001734-82.2010.8.26.0568: "(...) A diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não está inquinada de inconstitucionalidade. Trata-se de mecanismo que fornece ao Magistrado maior amplitude e liberdade de atuação para aferir no caso concreto a retribuição penal a ser suportada pelo transgressor, prestigiando o princípio constitucional da individualização da pena, direito fundamental insculpido no artigo 5º, XLIV, da CF. Todavia, referida redução não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". (destaquei) Ressalto que recentemente a jurisprudência do STJ já admitiu a possibilidade de a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes serem considerados tanto para aumentar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme o artigo 42 da Lei de Drogas, quanto para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11343/06, na terceira etapa da dosagem da pena. O acórdão foi redigido dessa maneira: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5.

Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 578.782 – SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j.04/08/2020, destaquei). A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal já admitiu essa possibilidade, conforme julgado adiante citado:

Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado com base na hediondez já afastada por ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 4. Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. 6. Determinação para que o juízo da execução, afastando a hediondez, fixe de forma fundamentada o novo regime de cumprimento da pena ainda não realizada. 7. Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. nos Emb. Decl. no HC nº 154462/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Gilmar Mendes. j. 30.11.2018, unânime, DJe 06.12.2018, destaquei). Nesse julgado constou que o não reconhecimento da causa de diminuição decorre da participação em uma rede de traficantes. Embora a ré seja tecnicamente primária, infere-se que as circunstâncias do caso concreto levaram a crer que ela é criminosa habitual, evidenciando não ser merecedor da benesse. Por fim, o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece que o Juiz poderá reduzir a pena, ou seja, é uma faculdade e não uma obrigação. Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda aferida e do salário-mínimo vigente na época dos fatos, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, da grande quantia de droga traficada pela ré, por ela já ter sido condenada anteriormente por tráfico de drogas, e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico. Justifico a fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena também pelo tráfico de grande quantia de drogas, a indicar um envolvimento reiterado com este tipo de crime, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Carta Magna. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. Orig. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.09). O crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Nesse aspecto, acerca da necessidade do regime mais grave para o tráfico de drogas, cito o voto do eminente Desembargador Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0004588-12.2016.8.26.0189, julgado em 21/09/2017: Esse desgraçado vício da cocaína chegou em nosso país e, principalmente, nessa cidade de São Paulo, onde todo mundo sabe que existem logradouros públicos, que foram praticamente tomados por viciados. É bom lembrar que o usuário de cocaína quando

não tem dinheiro para adquirir a cocaína pura, que é em forma de pó, passa a se utilizar de uma forma inventada nos Estados Unidos, mais, precisamente na cidade de Nova York, no início dos anos 1970, denominada crack, aliás muito mais potente no sentido de fazer com que apenas com uma aspiração da fumaça tóxica (coloca-se a pedra em um pequeno cachimbo, conhecido como "marica", geralmente de vidro, esquentando-se embaixo com uma chama de isqueiro ou fósforo, e a pessoa suga a fumaça que desprende da pedra de "crack") já se torna dependente desta desgraça que foi inventada por indivíduos alheios a qualquer sentimento de piedade e que tinham somente interesse em ganhar dinheiro. Ora, uma pessoa que transforma seu semelhante num morto vivo, ou seja, um verdadeiro zumbi, como os que se vê na mídia, principalmente televisiva, indivíduos convivendo juntos na maior sujeira e promiscuidade, sendo que os locais onde essas pobres almas habitam, tem que ser constantemente lavado, com jatos de água e detergentes, pela Prefeitura Municipal, a fim de remover o fedor que exala do chão devido às secreções e excrementos que essas pessoas deixam naqueles locais. Tudo o que disse acima, e que é do conhecimento de todos, acontece por apenas uma razão, devido à ação de pessoas destituídas de qualquer sentimento de amor ao próximo, como é o caso do traficante e, nesses autos, do acusado. Com relação à conduta social do recorrente, não há qualquer dúvida que, com sua atividade de traficantes, ele causou um mal irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente, foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas. O direito, como é cediço, é uma ciência mutável, ou seja, ele tem que acompanhar a evolução humana, e se adaptar às suas necessidades que mudam a cada época do desenvolvimento da sociedade. Assim sendo, como uma das finalidades da pena é intimidar um possível criminoso, é mais do que óbvio que um crime como o tráfico de drogas, que, sem falar nos males causados à pessoa humana, abre as portas para inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, homicídios, prostituição etc.; não pode receber um tratamento menos gravoso do que um delito de menor potencial ofensivo. Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de ser preso não há outro regime, senão o inicial fechado, como forma de contraprestação do Estado à sua conduta. Fixar-se um regime mais benéfico do que o inicial fechado, seria conceder-se uma benesse ao réu, a qual ele não é merecedor. Cumpre observar que o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade do interior. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR a ré Caroline Sales Bento, qualificada nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incursa no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; b) CONDENAR a ré Caroline ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98 § 3º, do CPC, pois lhe concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) ABSOLVER o réu Julio Henrique Venâncio Batista, qualificado nos autos, da acusação de ter incorrido no delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com arrimo no art. 386, VII, do CPP. Diante do resultado do julgamento expeça-se alvará de soltura do réu Julio para que seja colocado em liberdade se não tiver preso por outro motivo. Defiro à ré Caroline o direito de apelar em liberdade, haja vista que foi agraciada com a liberdade provisória e não surgiu motivo apto a ensejar sua prisão. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Expeça-se ofício à 2ª Vara Criminal de Assis solicitando o envio com urgência da certidão de objeto e pé relativa ao processo criminal nº 1500692-17.2019.8.26.0047, no qual figura como ré

Caroline Sales Bento. Expeça-se ofício à Autoridade Policial autorizando a entrega do veículo apreendido em favor do proprietário Julio e que se não providenciar a retirada no prazo de 90 dias, diante da nova redação do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria de Justiça, fica autorizada a Autoridade Policial a dar destinação ao bem apreendido, na forma do artigo 123 Código de Processo Penal. Instrua-se com o auto de exibição e apreensão. Expeça-se mandado de levantamento judicial do dinheiro apreendido em favor do réu. Após, intime-se o réu Julio, por publicação aos Advogados, para efetuar a retirada do seu veículo apreendido e dinheiro, no prazo de 90 dias, sob pena de perdimento dos bens. Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Caso a condenação seja mantida após eventual recurso e decisão de instância superior, expeça-se mandado de prisão em desfavor da sentenciado, constando o regime definido no acórdão; 2) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 5) Requisite-se a incineração da droga; 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 11) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 12) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 13) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 14) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva. Em seguida, o(a)s Defensor(a)(es) e o(s)réu(s) Caroline manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos.1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo pela Defesa, intime-se para apresentar no prazo de 24 horas. 3. Se não fizer, intime-se o réu para constituir novo Advogado no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de que se não o fizer será nomeado Advogado Dativo. 4. Decorrido o prazo, nomeie Defensor Dativo junto à OAB e intime-se-o para apresentar as razões recursais no prazo legal. 5. Após a apresentação, abram-se vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Por fim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 07 de agosto de 2032. Saem os presentes intimados". Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, Maria Augusta Rocha Mantovani, escrevente ad hoc, digitei.